【文章编号】1002－6274(2009)02－046－05

“地票”的法律性质和制度演绎

郭振杰[1]　曹世海[2]
(1. 贵州民族学院法学院，贵州 贵阳 550021；2. 重庆市第一中级人民法院，重庆 400020)

【内容摘要】重庆市在全国率先推出的“地票”制度对我国农村建设用地的流转具有重要参考价值。但地票具有其特有的法律性质，如特殊的法律权利主体和尚待其他配套制度明确的权利内容。地票重要的制度价值体现在其逻辑展开和制度演绎上，农村建设用地复垦权的地票化、农村建设用地本身的地票化、甚至城镇建设用地的地票化，都将进一步体现“地票”的价值，并凸现土地资源的重要性。地票制度将大大促进我国农村土地的复垦、征用与城镇国有土地的出让、开发等工作中的社会利益协调，并为城乡土地提供统一交易的制度通道。

【关 键 词】地票　法律性质　制度创新　城乡统筹
【中图分类号】DF41　【文献标识码】A

2008 年 12 月 4 日，重庆农村土地交易所正式挂牌成立，成为全国首家农村土地交易所，该交易所将主要进行地票挂牌交易，“地票”由此诞生。在中国改革开放三十年之际，重庆以制度创新的姿态，在城乡统筹方面写下浓重一笔，中央人民政府网站对此进行了宣传[1]。作为一个新生事物，地票的法律性质仍存在不清晰之处，与其伴生的许多问题仍需要深入研究探讨，并通过配套制度的不断完善来实现其独特价值。

一、地票的概念和地票的形成

按照《重庆农村土地交易所管理暂行办法》第 18 条的规定，重庆农村土地交易所交易的地票，指“包括农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地，经过复垦并经土地管理部门严格验收后产生的指标”。因此，首先需要廓清的是，就目前制度而言，地票首先不是“土地”的“票据化”，也不是“土地权益”的“票据化”，更不是农村土地“承包经营权”的“票据化”，而是“指标”的“票据化”。

按照指标的产生流程来分析地票的形成，则依次可分为四个环节，即专项规划、复垦申请、复垦验收、核发地票。具体而言，市国土资源行政主管部门首先依据土地利用总体规划、城镇规划，编制相关专项规划，经市政府批准后实施；其次，由农村土地权利人向区县国土资源行政主管部门提出土地复垦立项申请，经批准后复垦所立项的土地；第三，在土地复垦完毕后，复垦方向区县国土资源行政主管部门提出农村土地复垦质量验收申请；第四，区县国土资源行政主管部门按规定组织验收，验收合格后，按照重庆市土地复垦有关规定，向市国土资源行政主管部门申请确认，并由其核发地票。

地票是“指标”，该指标是建立在对农村集体建设用地的复垦前提之下。首先有复垦，才有耕地增加；有耕地增加，才有指标；有了指标，才有可以交易的地票。所以，地票的出现和交易决不会使耕地减少，也不会影响农村土地承包经营权的转移，更不会导致耕地性质的变更。这是探讨地票制度必须明确的基本前提。

二、地票的制度创新价值

尽管地票的法律属性仍不十分明确，相关制度也急需配套，但我们首先要从制度创新的角度对这一新生事物以积极的审视，在此基础上，完善相关制度。

(一)地票与农村土地流转

在我国逐渐放开农村土地承包权的转让、出租、

作者简介：郭振杰(1971－)，男，河南安阳人，法学博士，贵州民族学院客座教授，重庆社会科学院副研究员，研究方向为经济法学；曹世海(1974－)，男，河南商城人，法学硕士，重庆市第一中级人民法院干部，研究方向为司法制度。

中国知网 https://www.cnki.net

入股后,农村土地承包经营权的证券化已经成为一个可资借鉴的思路。地票的出现,为权利证券化提供了一个新的制度进路。既然指标可以作为交易的客体,那么产生指标的权利本身,如复垦权是否可以成为一种附限制条件的地票? 比复垦权更为基本的农村建设土地的集体所有权,是否可以直接进入地票的范围,成为交易的对象? 按照此思路,则可以把地票制度进行扩充完善,使之成为解决农村土地流转的一个基本模式。因此,在不改变现有国家土地制度尤其是农村集体土地所有制的前提下,地票已经为农村土地流转进行了最好的制度创新尝试,其价值不容小觑。

(二)地票与城镇土地开发

地票的出台,占据了城乡统筹发展的先机,成立农村土地交易所,也是为城镇农村土地进行统一交易而迈出的重要一步。但其优先针对的问题,仍是城镇土地开发与耕地日益减少的矛盾。在地票制度推出后,地票将成为城镇可开发土地存量的重要指标。既然农村建设用地复垦产生的指标可以形成地票,那么同理,城镇旧城改造,废弃土地平整产生出来的可用城镇建设土地,也可以形成地票,当然,此地票不再是指向可以增加城镇建设用地的指标,而是直接代表可以进行建设的城镇建设用地的存量,将直接影响城镇建设土地的供应,决定土地市场价格。如此,则城乡的建设土地在地票上形成一个可以拉通计算的平台,对城镇的建设和发展也是重要的制度创新。

(三)地票与土地流转制度瓶颈的解决

农村土地除了耕种的自然用途之外,对农民具有强大的吸附作用,具有凝聚农村的社会价值,因此,农业部的《农村土地承包经营权流转管理办法》规定,土地承包经营权的转让必须是“承包方有稳定的非农职业或者有稳定的收入来源”前提下,才能“经承包方申请和发包方同意,将部分或全部土地承包经营权让渡给其他从事农业生产经营的农户”①。土地,本是万物之母,是不可再生资源,但是,由于土地无法实现市场流通,也就没有市场价格,最终土地的价值无从体现,农业人口占有土地却不拥有财富。在农业改造和土地制度创新的过程中,地票制度首先使土地的价值可以在一个开放的市场中得到承认——哪怕只是附属在土地上的复垦后的若干权利——这无疑为拥有土地但并不富裕的广大农村居民打开了一扇崭新世界的大门。在今后地票制度的完善中,地票的价值和土地的特性、土地信息等连在一起,土地及其权利的价值将通过地票市场得以体现,为此将解决土地流转的制度瓶颈。更重要的是,地票如果使城镇土地和农村土地在一个市场上得以无障碍地交易,则对促进城乡统筹发展、建设和谐社会,发挥重要的制度价值。

(四)地票与法律制度的“构建”

美国大法官霍姆斯曾说过“法律的生命并非逻辑,而是经验”,中国秉承欧陆法系的传统,更注重成文法的体系和法学理论的逻辑,法学研究也多关注正义和公平。但是,法律是什么,这个简单的法律本体论的问题仍需要给予正面的回答。对《中国法学向何处去?》[2]这个问题的回答,需要首先明确“法律是什么”。制订法律不应该是“外国法律制度的移植”,尽管移植制度可以在很快的时间搭建起完备的法律体系框架。法律是各种利益诉求在搏弈中形成的一个各方不得不遵守的一套规则,它既有“命令”,也有“授权”[3],法律不是理论上的逻辑论证,也不是利益诉求在保守的制度前的屈从和裹步。地票的出现,为城镇和新农村建设中不同利益主体的合理诉求表达提供了法律制度平台,甚至在一定程度上回答了“究竟是制度塑造社会,还是社会塑造制度”这一难题[4]。法律不是法学家构建或期盼的、文字写作的对象,而是活生生的社会创造、社会运转的规则所在。在这个意义上,地票的制度价值远比文字论证构建法律更有价值。

三、地票的法律分析

地票是个新事物,这个新事物能不能定型、成熟,发挥其制度价值,要看其法律属性是否明确,地票之上的权利义务界限是否清晰。如果地票在法律层面没有一个清楚的权利义务内容,则地票的制度价值将大打折扣,其市场流通价值也将因其权利的模糊性而遭贬损,最终会导致有票无价,或有价无市而不了了之。

按照官方的定义,地票是种“指标”,地票的交易就是指标的交易。因此,地票的特征都从指标的特征衍生而来。而“指标”,严格来说,就是一种授权性政策规定,即如果拥有某种指标,则有资格有权利做某种行为。比如招生指标、生育指标、出国留学人员归国后购买免税车辆的指标,都是表明拥有指标者可以招收学生、生育孩子、减免特定税费购买车辆等。在防止全球变暖的国际条约中,排放二氧化碳的总量对条约签字国也是“指标”。简要地说,指标是一种资

中国知网 https://www.cnki.net

格，一种权利。

（一）地票的权利主体

地票由政府核发给农村集体，在上市交易后转让给其他市场主体，因此，地票的权利主体主要有政府、农村集体、地票持有人等。

按照地票制度的设计思路，通过农村建设用地的复垦产生地票指标，这种指标的首要功能就是“可以纳入新增建设用地计划，增加等量城镇建设用地”。所以，地票产生以后，则产生了增加城镇建设用地的“资格”、“权利”。但在我国现有土地制度下，是否及如何增加城镇建设用地，显然不是地票持有人所能决定和操作的，这些仍是政府的权力。也就是说，拥有地票并不当然地拥有地票所记载的“城镇建设用地”，因为城镇建设用地的增加必须借助政府的公权力来将城镇周边非建设用地通过“征用”，再经过“平整”后才能成为可以出让、开发的建设用地。因此，问题在于，地票所带来的增加等量用地的“权利”到底属于地票持有人还是政府？如果属于政府可以征用增加相同面积非城镇建设用地的权利，则地票拥有者的权利又将如何体现？地方政府行为失范在土地领域已经表现得非常突出[5]，而地票制度，这个从一开始就由政府绝对主导的制度，如何防范政府的行为失范，就成为一个需要研究的重要问题。

（二）地票的权利内容

对于通过土地交易所购买地票从而持有地票的人而言，地票带来的权利如何体现？地票持有人是否获得国有城镇土地使用权出让时的优先权？如果有此优先权，则地票的交易和竞价就有了基础，但是，按照土地使用权公开的招拍挂制度，持有地票，并非是进入土地交易的资格证明。所以，地票并不是土地交易市场的“入场券”，也并不能享有交易条件相同情况下的“优先权”。

地票“在落地时冲抵新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费”，地票持有人享有地票落地时冲抵有关费用的权利，是可以量化的权利，也将是地票价值的直接体现。问题是，这种冲抵，是按照什么标准来冲抵，是第一次的挂牌价，还是在流通中的交易成交价？如果是第一次挂牌价，则说明该地票的价格是固定的，而固定价格的商品根本没有交易流通的可能。但是如果是按照此后的市场交易成交价，考虑到成交价与抵扣费用的直接挂钩，无疑会出现操纵市场，形成高得离谱的成交价。指标费用的冲抵办法，正在重庆市土地行政主管部门制订过程中，也许，地票制度的生死前途，就看冲抵办法的具体规定了。

对于通过复垦而拥有地票的农村集体（包括农村居民）而言，权利和收益体现在有权转让地票并收取相应的对价。对价的大小决定了他们的收益，但对价同样取决于地票转让后的价值实现机制上。

（三）地票的登记和抵押

如果地票可以给地票持有者带来可以预期的价值，则地票的交易价值就有了基础，按照市场的供需关系最终可以形成市场价格。农村土地交易所已经为地票的交易提供了公开的市场平台，所以，相比地票的价值，其流转已经不是特别的障碍和难题。

既然地票有价有市，而且是可以转让的权利，则在地票上设立抵押权则水到渠成。地票持有人可以用地票融资，这将大大推动地票的流通和交易，地票市场将为之活跃。为保证地票的有序流转，应该明确地票的登记制度，并配套其抵押或质押的有关规定。既然已经设立了农村土地交易所，地票的抵押登记机构也可以顺理成章地设置在土地交易所。当然，地票的入场交易制度是否可以突破，值得进一步研究。

（四）地票的价值构成

抛开此前分析的权利归属和市场价格的形成，地票的价值由如下因素来决定：1. 复垦的费用。按照目前对地票的定义，地票必须是有关建设用地复垦后，才能产生的指标，因此，复垦费用是地票价值的首要构成；2. 决定复垦的决策成本。农村的建设用地，如果要进行复垦，必须经过集体三分之二多数通过才能进行，因此，决定是否对某块建设用地进行复垦，涉及到基层组织的会议召开、议题讨论和表决，在农村劳动力大量外出务工和长时间不回乡的具体情况下，这种成本也是不小的；3. 申请、报批、验收等工作成本。如果申请、报批和验收形成制度，则这种成本相对容易减少；4. 地票价值实现的不确定性带来的风险收益。如果地票权利不能实现，或者因为制度的滞后性导致其地票价值的实现不畅，则初期的地票当有相当程度的风险投资价值。

（五）地票制度的正当性

地票制度是科学发展观指导下的统筹兼顾的完美例证，但在制度正当性上并非无懈可击。地票制度涉及到农村集体建设用地、农村耕地、城镇建设用地等各方面，但现有制度的行政主导色彩过于显著，各方的利益诉求并没有在相关制度的设计过程中得到

中国知网 https://www.cnki.net

充分表达。按照哈贝马斯的法律观,现代社会里,法律的正当性来自民主的立法程序,民主的立法的社会基础是沟通理性在公共领域的发扬[6]。地票,如此影响广泛的制度,仅在半年的时间里便由设想成为现实,抛开其权利义务的合理性,其正当性将备受考验。

四、地票制度的逻辑展开和制度完善

(一)地票的效用与目的差距问题

在地票制度的设计过程中,国家调研组曾专程来渝调研,肯定了重庆筹建农村土地交易所的基本方案,支持“设立重庆农村土地交易所,探索开展地宗交易和指标交易,逐步建立统一的城乡土地交易市场”,“提升农村特别是偏远地区的土地价值,将有效地促进农民增收和改善农村生产生活条件”。[7]然而,复垦后产生的指标价值和农村居民拥有的土地价值是两码事。地票的产生依赖于土地的复垦,地票的转让成交价,减去复垦的成本,才是地票给农村集体带来的净收益。仅仅转让地票的收益,对提高农民的生活质量恐怕并不可观,也不持久。因此,地票的产生,与城乡土地统一交易之间的差距还相当巨大。

解决效用和目的差距问题,应把地票制度逻辑展开,充分认可土地及其附属权利的价值。

(二)复垦权的地票化

如何减少和扭转农村建设用地的闲置和浪费,是城镇化建设过程中值得研究的问题,而地票的引入,使得对该闲置土地进行复垦成了具有市场价值的行为。复垦是地票制度中的核心环节。因为复垦使我们能够有效利用农村建设用地、增加耕地、产生新增城镇建设用地的指标。但是,在农村生产回报不高、土田抛荒现象严重的情况下,对闲置的建设土地进行复垦,不仅仅是该土地所有人的决策问题,资金投入更是一个关键问题。筹集大量资金,花费相当的人力物力进行复垦,如果没有政策的倾斜和政府的主导,在现有农村土地集体所有和劳动力零散配置的具体情况下,困难重重。

复垦毕竟不是以家庭为单位进行投入的短平快项目,而是一个需要有组织、有资金、有规模的生产过程。因此,如果将复垦的权利法定化,并使之可以转让,或者干脆“地票化”,则该土地所有人本来难以实现的远期利益将转化为具体的即期利益。而受让复垦权的受让人,则可以通过集约化、专业化的管理组织,来实施对该土地的复垦。持有复垦权地票的人,也可以通过交易所公开拍卖转让复垦权,使资源的配置达到最优,让农村建设用地复垦成为有利可图的可持续进行的事业。

(三)农村建设用地的地票化

如果复垦权通过地票化可以达到增加耕地、优化土地、发现资源价格、保护农村居民权益等制度目标,则可以进一步探讨农村建设用地的地票化。既然复垦权可以地票化,作为复垦权得以存在的农村建设用地本身,当然也可以地票化。而且这种地票化的优势是显而易见的:缩短了土地所有者权利实现的链条,对权利人而言更为具体、可靠;促进更科学更长远地对可以复垦的农村建设用地进行整体规划;为建设用地的集中复垦和统一复垦计划提供了制度支撑。另外,由于农村宅基地、建设用地大多都有零散、面积小的特征,如果不化零为整,则很不容易体现出指标的价值。而农村建设用地的地票化,为化零为整统一开发提供了基础。

(四)城镇建设用地的地票化

在城镇开发建设过程中,由于旧城改造、危房拆迁、工厂改制以及规划和建设的调整,形成了大量的、零碎的、使用权人不统一的城镇建设用地,甚至出现了“城中村”。笔者认为,可以引用地票制度,来整合这些零散的土地,并进行整体开发。

农村建设用地可以通过复垦来实现土地资源的优化,而城镇建设用地也可以通过地票化来完成对零散地块的整合,对闲置土地的开发。城镇建设用地的地票化将为城镇国有土地出让带来巨大的变化,也为统一的土地交易市场制定了产品标准。

(五)统一的城乡土地交易市场

“建立统一的城乡土地交易市场”是土地市场的发展方向。而城乡土地交易市场的统一,必须建立在交易产品的统一基础之上,否则,就只能是在一个看似相同的市场里,分别进行交易。而农村建设用地的地票化以及城镇建设土地的地票化,将为交易市场提供可以折算、可以比较的同类产品。不同类别土地产生的地票,也许在市场初期存在差异,但在市场的交易过程中,则这种差异将由其价格来体现。一旦地票的差异只存在于价格差别方面,则市场的统一也就自然达成。

结语

地票制度的引入,对促进城市建设用地有序增

中国知网 https://www.cnki.net

加,推动新农村建设,保护农业耕地,有效利用土地资源具有重要意义,将在我国经济建设中发挥重要作用。最为重要的是,地票为土地权益的证券化提供了一个制度平台,将大大拓展有关土地制度改革的制度空间。

中国地票的产生,重庆市政府和主管领导居功至伟,但由于行政主导色彩过于强烈,加之从提出设想到制度出台的酝酿消化不足,从法学、经济学和社会学等方面的论证并不十分充分。虽然有人说"中国的法律人目前大多并没有真正的中国问题意识,他们发现的中国问题都是从书本上来"[4],但是"如果缺乏训练有素的专家的决定性配合,就不可能有正式阐述的法律"[8]P86。许多问题都会在实践中渐次呈现,为理论研究和制度完善提供了丰富的题材。地票的化零为整问题、地票制度与现有国有土地制度和农村土地制度的衔接问题也非常重要,都是需要深入研究的重要课题。但是,地票制度逻辑一旦展开,则其制度价值将逐一显现,复垦权的地票化,农村建设用地的地票化,继而城镇建设用地的地票化,以及城乡统一土地市场的形成,都将是这一逻辑展开的制度成果。可以说,从制度创新意义上讲,地票化其实是利用土地权利的证券化来实现城乡统筹、科学发展的一个重要制度进路。

注释:

① 参见:《农村土地承包经营权流转管理办法》第35条。

参考文献:

[1] 刘潺.重庆首个农村土地交易所正式成立[EB/OL].http://www.gov.cn/jrzg/2008-12/04/content-1168702.htm.
[2] 邓正来.中国法学向何处去(上)——建构"中国法律理想图景"时代的论纲[J].政法论坛,2005,1.
[3] 喻中.哈特的"授权规则"及其本体意义[J].北京行政学院学报,2004,4.
[4] 苏力.面对中国的法学[J].法制与社会发展,2004,3.
[5] 李龙浩.土地问题的制度分析:以政府行为为研究视角[M].北京:地质出版社,2007.
[6] 陈弘毅.从哈贝马斯的哲学看现代性与现代法治[A].陈弘毅.法理学的世界[C].北京:中国政法大学出版社,2003.
[7] 何青枚.重庆副市长就成立农村土地交易所答记者问[EB/OL].http://cq.house.sina.com.cn/news/2008-12-04/152921825.html.
[8] [德]马克斯·韦伯.论经济与社会中的法律[M].张乃根译.北京:中国大百科全书出版社,1998.

The Legal Property of the Land Quota and Its Flawless System

Guo Zhen-jie[1] *Cao Shi-hai*[2]

(1.Law School of Guizhou University of Nationalities, Guiyang Guizhou 550021;
2.Chongqing No.1 Intermediate People's Court, Chongqing 400020)

【Abstract】Chongqing rural land exchange has made a new market in China, and makes the Land Quota a new kind of product. The legal property of Land Quota has its special characters such as the subjects or the right of it. According the Land Quota, we can build a flawless system. Securitilizing the right of re-farming in the rural, the right of the construction land itself, even the right of the construction land in the suburb or in the city, is a right way for the coordination of rural and suburb, a important innovation of the scientific development. By means of Land Quota, we can make a union land market between the rural and the suburb.

【Key words】Land Quota; legal property; innovation; coordination of rural and suburb

(责任编辑:黄春燕)

中国知网 https://www.cnki.net